



はじめに

大学で憲法学を研究し教える立場にある者が、憲法学修を進める学生たちに多少なりとも深く知っておいてもらいたい「基本概念」を取り上げ解説するよう依頼されたとする。取り上げる基本概念は、学修過程で頻出するにも関わらず講義や教科書では意外に詳しく説明されることが少なく、したがって改めて正確な知識や理解を問われると学生が戸惑ってしまうようなものが良い。そして、それをきちんと学んでみると今後の学修がより面白く感じられるようなものであればなおさら良い、と。依頼を受けた論者それぞれの学問的な関心や教育上の主眼のありかによってその選択には差異があるだろうが、おそらく多くの者が、「立憲主義」や「人権」（基本権）、あるいは「権力分立」や「議院内閣制」、さらには「公共の福祉」といった概念をまず候補として思い浮かべるのではないだろうか。

本稿は、筆者がそのような依頼を受けたと仮定して、以上のような基本概念をいったん候補にして逡巡した挙げ句、「憲法」という概念を

選び解説を試みるものである。数ある候補のなかから「憲法」を選んだのは、「立憲主義」と「人権」の両概念については筆者自身がかつて別所で物したことがあるし、また、それらを収録して編んだ書には、「権力分立」や「議院内閣制」、「公共の福祉」といったその他の基本概念についての鋭い論者による論攷が収められているから、という理由だけによるのではない¹⁾。

本稿が述べる「憲法」概念についての解説は、今後、読者が学修を進めるうえで、折りに触れ、本稿で述べられていたのはこういうことであつたのかと合点がいくような機会を得られるはずの内容であり、そのような、いわば腹落ち体験を通じてこそ憲法学修にいつその興味をもち、それがさらに深められるだろうと期待できるからである。そのために、とくに憲法と他の実定法とのあいだにはいかなる共通点があり、またいかなる違いがあるかを意識しながら読み進めてもらえると良いと思う。

1 constitutionと「憲法」の距離

「“憲法とは法律の一種だ”とあなたがもし考えているとすれば、それは大いに不正確である。」——これは、ある著名な憲法学者の教科書にある言葉である²⁾。もちろん、法学部の新生でなく上級生であれば、憲法と法律の違いの1つや2つくらいは容易に指摘できるはずである（たとえば制定者が違う、形式的効力や改正方法が違う、あるいは主たる名宛人や目的が違う、など）。これほど違いがあるのだから、「法律の一種だ」としてしまうのはやはり不正確であると言えそうである。この程度はおそらく難く理解できるだろう。しかし、この言葉の直前に書かれているつぎの一文はどうだろうか。そこには、「われわれが『憲法』という言葉聞いたとき、第一に、“それは法の一種だろう”と直感し、第二に、“日本国憲法のように、成文化された法のことだろう”とイメージするだろう」、とある。しかしそれは、この憲法学者に

1) 「立憲主義」については南野森「立憲主義」同編著『憲法学の世界』（日本評論社、2013年）2-14頁を、「人権」については同「人権の概念——憲法・憲法学と『人権』」同書120-134頁を参照。そして同書には、「法の支配」[小林暁生]、「民主主義」[小泉良幸]、「国民主権」[小島慎司]、「権力分立」[赤坂幸一]、「議院内閣制」[林

知更]、「公共の福祉」[曾我部真裕]といった、本稿で取り上げる基本概念の候補になりうべきものが多数含まれている。

2) 阪本昌成『憲法I——国制クラシック〔全訂第3版〕』（有信堂高文社、2011年）11頁。

よると、「憲法」という日本語のせいで我々が「もってしまう」不正確な直感であり、イメージなのである。

現在の我々が用いる「憲法」という日本語は、幕末から明治初期にかけて、西洋語の constitution (英語、仏語) や Verfassung (独語) といった言葉の翻訳語としていくつもの候補のなかから選ばれ、大日本帝国憲法の制定 (明治22年 [1889年]) に先立つこと10年にも満たない頃ようやく定着していったものである³⁾。先人たちは、西洋の constitution という概念に出会ったとき、それを日本語で表現するために、あるいは古くからある漢語を転用したり、あるいは新たに造語を試みたりした。「国憲」 (加藤弘之、慶應4年) や「憲法」 (箕作麟祥、明治6年) などは前者の例である⁴⁾ し、「律例」 (福澤諭吉、慶應2年) や「朝綱」 (津田真道、慶應4年) などは後者の例であったろう。「建国ノ法」 (箕作麟祥、明治3年)⁵⁾ や「根本律法」 (津田真道、慶應4年) という長めの訳語も存在した。

そもそも、英語で言えば constitution は constitute という動詞から作られた語であり、つまりもともと構成とか骨格といったニュアンスをもつ語が、国家について用いられ、国家の構造を意味するとともに、その主要な部分を定めるテキストをも意味するようになった⁶⁾。国

家の構造を「国制」と呼ぶとすると、constitution とは、つまり国制のことであるとともに、国制について定めたテキスト類でもあるということになる。日本語で「憲法」と言う場合に、どうしても後者の一側面 (成典化されたテキストとしての「憲法」) ばかりが意識され、その他の側面 (国により時代により国制の一部分がたとえば不文の慣習により定められていることもあろう)、そして前者の側面 (「この国のかたち」) がややもすると無視されてしまう点が、おそらく冒頭の憲法学者の批判する「不正確」な「直感」なのだろう。

ところで、憲法学の教科書をひもとくと、しばしばその冒頭で憲法という概念についての説明が施されているはずである。そこで展開される形式的意味の憲法と実質的意味の憲法という区別は、以上の説明をふまえると、無味乾燥に結論だけを暗記すべき用語法としてではなく、翻訳を通して始まった近代日本の法学には元来不可避であるはずの、術語の「原義」に遡って理解することの重要性を示唆するものとして、その浅からぬ背景とともにより良く理解されることになるだろう。すなわち、形式的意味の憲法とは憲法典 (日本国憲法) のことであるとして、実質的意味の憲法とは、それとは別に存在が観念されるものであって、それはすなわち国制について定めたテキスト類のことである、と

3) 参照、南野・前掲注1)「立憲主義」3頁。法典の名称として「憲法」という訳語を最初に用いたのは箕作麟祥であったとされる (穂積陳重『法窓夜話』〔岩波文庫、1980年 (初出1916年)〕178頁参照)。箕作は、明治2年 (1869年)、新政府の参議であった副島種臣の命を受け、フランスのナポレオン法典 (民法、訴訟法 [= 民事訴訟法]、商法、治罪法 [= 刑事訴訟法]、刑法の5法典) 及び当時のフランス第二帝政憲法 (1852年) の、あわせて「六法」の大翻訳事業を開始する。明治3年 (1870年) に『仏蘭西法律書 刑法』がまず刊行され、その後、民法 (同年)、訴訟法、憲法 (明治6年 [1873年])、商法、治罪法 (明治7年 [1874年]) が出され、「六法」が完結した。箕作の法典翻訳事業については、山口亮介「明治初年の西洋法翻訳：箕作麟祥の試み」Chuo Online (読売新聞オンライン) > 研究 > 2019年度 <<https://yab.yomiuri.co.jp/adv/chuo/research/20200312.php>> を参照。

また、明治13年 (1880年) 頃までは「国憲」の語も政府内で用いられていた (1876～80年に元老院で3回起草された「日本国憲案」) が、その後、明治15年 (1882年)、憲法調査のため伊藤博文に欧州派遣を命じる勅語に付された訓令に「歐洲各立憲君治國ノ憲法ニ就キ其淵源ヲ尋ネ其沿革ヲ考ヘ其現行ノ實況ヲ視利害得失ノ在ル所ヲ研究スヘキ事」と記されて以降、「憲法」の語に一本化されていくことについて、山口亮介「〔連載〕法とことばの近代史／第12回〈憲法〉」ビジネス法務2021年9月号118-119頁も参照。

4) 「国憲」という漢語は、平安時代初頭の勅撰漢詩文集である『経国集』(827年)の巻20の掉尾に収録されている、奈良時代の官吏登用試験の論述問題に対する (模範) 解答案である「対策」(天平5年 [西暦733年]) のなかに、「因禮復讎、既違國憲、守法忍怨、爰失子道」(礼に因りて讐を復せば既に国憲に違ひ、法を守りて怨みを忍べば爰に子道を失ふ) とか「違國憲者不臣」(国憲に違ふ者は臣ならず) と登場するのが最初期の例のようである (小学館『日本国語大辞典』などを参照。訓読は津田博幸編『経国集対策注解』〔塙書房、2019年〕455頁に依った)。そして「憲法」という漢語は、周知の通り、『日本書紀』(720年)に登場する聖徳太子の「憲法十七條」(604年)が最初の例である。いずれも、今日の我々が用いる「憲法」という意味ではなく、たんに「法」とか「掟」の意味で用いられている。

5) 前掲注3)で紹介した箕作の『仏蘭西法律書』のうち、明治3年に刊行された『刑法』と『民法』では、「憲法」に相当する語として「建國ノ法」が用いられていた (刑法典第3部第1編第2章の標題と114条、116条に用いられている Constitution、そして民法典7条の loi constitutionnelle の4か所。ただし、刑法典118条の Constitution には「國法」の訳語が充てられている)。

6) 大林啓吾 = 見平典編著『憲法用語の源泉をよむ』(三省堂、2016年)所収の「憲法」欄 (2-9頁)、とくにイギリスについての部分 (4-6頁、溜箭将之執筆) も参照。

いうわけである。したがって、形式的意味の憲法のなかに実質的意味の憲法でない規定が含まれることもある⁷⁾し、実質的意味の憲法が形式的意味の憲法とは異なる存在形式をとることも当然ある。だからこそ、「憲法の法源」という論点が成立し、そこではいわゆる「憲法附属法」や「憲法関連法」と呼ばれる一定の法令が挙げられたうえで、それに加えて判例や慣習といった「不文法」がそこに含まれるか否かが論じられるのである。

なお、「憲法の法源」について注意しておくべきことがある。それは、そこで言われる「憲法」がいかなる意味であるのか、である。それが国制を定めるテキスト類という意味であるならば、「実質的意味の憲法の範囲を厳密に確定することは不可能であるし、そうする実益も少ない。実質的意味の憲法の範囲は、形式的意味の憲法の内容とも、また憲法学の研究・教育の対象とも論理必然のつながりがないからである」⁸⁾という説明がそのまま当てはまるだろう。これに対して、それが違憲審査の基準として用いられる「憲法」を意味するとなると、ことは様相を異にする。現在に至るまで日本の違憲審査の実務では、違憲・合憲の基準となる「憲法」は形式的意味の憲法に限定されてきたが、このことは必ずしも普遍かつ不変というわけではなく、たとえばフランスでは現行憲法典のほかに1789年人権宣言や「共和国の諸法律によって承認された基本原理」、さらには「憲法のアイデンティティ」なるものに違憲判断の基準としての地位が憲法院自身の判決によって与

えられている⁹⁾し、たとえば韓国では「首都はソウルである」という憲法典には書かれていない「慣習憲法」の存在が憲法裁判所の決定によって認定され、首都移転法が違憲と判断されたことがあるのである¹⁰⁾。

フランスや韓国のような違憲審査制の運用がみられるところでは、「憲法」の法源論が違憲審査の基準としての「憲法」の存在形式を問うものである場合、そこに何が含まれるかを最終的に決定する違憲審査権者の判断に影響を及ぼす可能性のあるものとして、憲法の最高法規性や硬性憲法性という論点とともに、それは、学説において激しい議論の対象になる可能性があることに注意が必要である¹¹⁾。

憲法典と「憲法」の距離

さて、ここで話は大きく変わる。

現在開会中の第211回国会の開会2日目にあたる2023年1月24日、参議院本会議においてつぎのような問答があった。岸田文雄首相に対し立憲民主党の羽田次郎議員が、「安全保障政策の大転換とそれに伴う膨大な国民負担をお決めになったのであれば、国民の信を問うのが当然です。1日も早く、国民の信を問うお考えがあるか、総理のご決意をお聞かせください。」として衆議院の早期解散を求めたのに対し、首相は、「何について、どのように国民の信を問うのか、ということについては、時の内閣総理大臣の専権事項として、適切に判断いたします。」と答弁したのである。

7) 有名な、「出血前に麻痺させることなく動物を殺すことは、一切の屠殺方法および一切の種類の家畜について例外なくこれを禁止する」というスイス憲法の1973年改正前の旧25条の2について、しかし、それがユダヤ人の宗教上の慣行を念頭に1893年の人民発案によって新設された規定であることに注意すれば、「実質的意味の憲法と無関係だといってしまふことはできないはずである」と指摘するものとして、樋口陽一『憲法〔第4版〕』（勁草書房、2021年）6頁を参照。

8) 長谷部恭男『憲法〔第8版〕』（新世社、2022年）3頁。

9) 「共和国の諸法律によって承認された基本原理（principes fondamentaux reconnus par les lois de la République）」については、長谷部恭男「共和国の諸法律により承認された基本原理」同『神と自然と憲法と——憲法学の散歩道』（勁草書房、2021年）233-244頁を、また「憲法のアイデンティティ（constitutional identity）」については、ミシェル・トロペール（松本有平＝長谷部恭男訳）「憲法の背後に？フランスにおける憲法のアイデンティティの原理」比較法学54巻2号（2020年）149-171頁を参照。

10) 首都移転を違憲とした韓国憲法裁判所の2004年10月21日判決は、移転法案を提出した盧武鉉大統領にとっての大きな政治的打撃ともなったが、その5か月前に同裁判所は同大統領に対する弾劾請求を棄却していた。このような、「同一人物に対して……示された真逆の性格を有する」判断が相次いだことが、「韓国政治における憲法裁判所という存在を国民の間で広く認識させる決定的な契機になった」として、同裁判所のあり方とくにその司法積極主義を「司法政治」の観点から分析するものとして、浅羽祐樹「韓国憲法裁判所における大統領弾劾審判の比較研究——盧武鉉と朴槿恵」年報政治学69巻1号（2018年）96-122頁を参照（引用部分は114頁）。

11) フランスの状況に関心のある読者は、アルメル・ル・ディヴェレック（只野雅人訳）「混乱した憲法秩序——名状しがたい、不安定なフランス憲法」山元一＝只野雅人編訳『フランス憲政学の動向——法と政治の間』（慶應義塾大学出版会、2013年）219-231頁、およびオリヴィエ・ポー（南野森訳）「フランスにおける憲法概念の歴史——政治的憲法から法的地位としての憲法へ」同書163-200頁を見てほしい。

衆議院を解散するというのは、衆議院議員の全員を憲法上の任期に関わらず一斉にクビにすることであるから、その権限はきわめて強大であると言わねばならない。そのような権限の行使が首相の自由裁量に委ねられるとするなら、「全国民の代表」（憲43条）であり「国権の最高機関」（同41条）を構成するはずの衆議院議員に対して、首相の権限が大きくなりすぎるようにも思える。はたして、解散権行使が認められる場合は限定されるべきではないのだろうか。このような問題をめぐり、かねて憲法学においては議論があるが（解散権論争¹²⁾）、それはいまだに決着がついているわけではない。

解散権の所在や限界をめぐる議論についての詳細は教科書等で学んでもらうとして、ここでは、憲法テキストと憲法政治の距離という観点から、いくつかの指摘をしておこう。

まず、憲法が解散の行われる条件について規定しているのは69条であるが、戦後行われた25回の解散のうち69条の条件——内閣不信任案の可決または内閣信任案の否決——が満たされて解散が行われたのは4回に過ぎない。残る21回は、69条の条件が満たされていないにも関わらず、憲法7条3号の天皇の国事行為を利用して行われた。実務においてはもちろん、学説においても69条の場合以外にも解散は可能であるとする「非限定説」がほぼ確定しているとは言えるが、しかしその根拠として政府見解や通説の見解が採用する7条説に対しては、依然として学説において有力な批判がある¹³⁾。

また、解散が「内閣総理大臣の専権事項」であるか否かについては、歴代の首相答弁でも、また政府見解でも、解散権が内閣総理大臣ではなく内閣にあることが繰り返されてきた¹⁴⁾（だからこそ、「閣議の合意を得る見とおしを持つことができなかった〔三木武夫首相〕は、みずから望む解散総選挙をおこなうことを断念し」¹⁵⁾たし、小泉純一郎首相は、「郵政解散」に反対した農林水産大臣をわざわざ罷免して解散の閣議決定をする必要があったのであった）。岸田首相の発言は、つ

まり誤りである。

さらに、最近では、時の内閣が自由に全衆議院議員のクビを切るなどということが許されるのがそもそもおかしいはずで、「内閣による解散権の行使を限定する、とくに政府・与党にとって有利な時機に総選挙を施行するという党派の利益に即した解散を禁止する」¹⁶⁾ことの必要性が学説においても認知され、そのための方法が種々提案されている¹⁷⁾。たしかに、「解散権が政治的に濫用されないためには、濫用を許さない有権者の成熟した反応が選挙結果によって示される以外に、最終的なきめ手はない」¹⁸⁾としても、その選挙結果自体が、内閣・与党の賛成がなければ改正されえない選挙制度と内閣・与党（内主流派）の選択する解散＝総選挙の時機に大きく依存する以上、結局は、それもさほど期待することはできないと言わざるをえない。

憲法の主たる目的の1つは、公権力を統制することにある。「いうまでもなく憲法は、主権者たる国民が国の統治のあり方を縛る法規範であり、政治といえどもこれに背くことは許されない」¹⁹⁾とも言われるとおりである。「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」（前文）すると宣言する日本国憲法下において、その代表者（の半分）の地位がひとり内閣総理大臣の「適切〔な〕判断」にのみ依存するなどという主張は、法的に正当化される余地はないはずである。しかし、法的に正当化される余地はないということを法的に確認する術もまたないのが、現在の「この国のかたち」なのである。周知のように、最高裁は、解散の合憲性審査を初めて求められた際、「現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章について適用を誤ったが故に、法律上無効であるかどうか……のごときは裁判所の審査権に服しないものと解すべきである」と10対4の多数決で決定した²⁰⁾。以来、「統治行為論」は一人歩きをし、解散の合憲性を裁判所で争うことはできないものと一般に解されてきた。

12) たとえば、上田健介「衆議院解散権の根拠と限界」憲法の争点（2008年）242-243頁を参照。

13) たとえば、樋口・前掲注7)386頁以下、長谷部・前掲注8)401頁以下を参照。

14) たとえば、宮沢喜一首相による1992年1月29日衆議院本会議答弁、小泉純一郎首相による2005年7月13日参議院本会議答弁、茂申俊内閣法制局長官による1984年8月2日参議院法務委員会答弁など。阪田雅裕編著『政府の憲法解釈』（有斐閣、2013年）176-182頁を参照。

15) 樋口・前掲注7)390頁。

16) 長谷部恭男「内閣による自由な解散権？」同『憲法学の虫眼鏡』（羽鳥書店、2019年）57-62頁、61頁。

17) 筆者の見解については、朝日新聞2014年11月18日朝刊掲載のインタビュー「解散の大義ってなんだ／伝家の宝刀、無制限に使えぬ」の参照を乞う。

18) 樋口・前掲注7)391頁。

19) 阪田雅裕「憲法9条の死」世界966号（2023年）23-30頁、29頁。

憲法条文と憲法政治の乖離とおぼしき事例に対し最高裁が違憲審査権限を行使しないのは、もちろん解散権に限ったことではない。たとえば憲法 53 条後段に定めのある「いずれかの議院の総議員の 4 分の 1 以上の要求」に基づく内閣の臨時国会召集決定義務が内閣によって合理的期間内に果たされない問題もそうであるし²¹⁾、内閣総理大臣による靖國神社参拝と憲法 20 条 3 項の関係についてもそうである。憲法尊重擁護義務（憲 99 条）を負う国会議員（元首相）が日本国憲法を「みっともない憲法」と侮辱してもなにか法的な制裁があるわけではない。そして、憲法 9 条と自衛隊や自衛隊関連法制の適合性については、改めて言うまでもない。内閣による衆議院の解散については憲法条文に欠缺があるかもしれないのに対し、これらの事例については明確に憲法条文が存在するように見えるにも関わらず、最高裁の判断はない。

「最高裁判所が日本において妥当すべき憲法テキストの意味すなわち憲法規範を最終的に確定する権限を有する機関である」以上は、「最高裁判所による憲法判断が下されなければ、未だ個別の条文の意味は確定しないままである」ということになる²²⁾。憲法典はたしかにそこにあるが、「憲法」は、控えめに言って流動的・動態的でしかなく、あえて言えばまだそこに存在していない、とさえ言えるかもしれないのである²³⁾。

20) 最大判昭和 35・6・8 民集 14 卷 7 号 1206 頁。小島慎司「苦米地事件」論ジュリ 17 号（2016 年）34-40 頁を参照。

21) 「憲法 53 条が、第 2 次安倍政権以降の 3 代の首相の下で蹂躪され続けている」ことについて、蟻川恒正「『解釈変更』という擬態」世界 966 号（2023 年）31-43 頁、42 頁の注 12）を参照。また、南野森「安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である」ヤフーニュース（個人）〈<https://news.yahoo.co.jp/byline/minaminoshigeru/20151024-00050752>〉も参照。

22) 南野森「『憲法』の概念——それを考えることの意味」長谷部恭男責任編集『憲法と時間〔岩波講座憲法(6)〕』

おわりに

いまから 40 年以上前と少し古くなるが、昭和の偉大な憲法学者のなかには、その教科書の冒頭で、「『憲法』と聞いて憲法典しか考えないようでは、学問は始から駄目である」と厳しく書く人もいた²⁴⁾。碩学に倣ってそこまで厳しいことを言うつもりも、また言える準備も筆者にはないが、本稿は、読者が憲法学修を進めるうえで、「憲法」という日本語、概念それ 1 つをとってみても多様な意味や背景があることを知ることが、憲法というものの特質を理解することにつながると考え、その解説を試みた。

そもそも憲法（「規範」）によって政治（「現実」）を統制しようとするのが立憲主義という企てであるとする²⁵⁾、それはもともと容易ならざるプロジェクトのはずである。そしてその実現に主力級の貢献を期待されているはずの違憲審査機関が、いくつかの立憲主義国のそれに比べると際だって消極的であると評価されざるをえないわが国の場合、なおさらである。政治は憲法によって制御されねばならず、現実には規範によって統制されねばならぬとしても、政治が憲法から遠ざかれば遠ざかるほど、憲法の統制力は低下したと評価され、その結果立憲主義を「復権」させるために今度は規範を現実に合わせてべきだという主張が説得力を増すことがある²⁶⁾。こと 9 条について言えば、「9 条の死文化を言い募る」のか、それとも特定の現実について「9 条違反の疑いがあると告発し続ける」のか²⁷⁾、政治の法（*jus politicum*）としての憲法学の前には厳しい選択がある。

（みなみの・しげる）

（岩波書店、2007 年）27-50 頁、37 頁。

23) 関連して、「保障される憲法」と「憲法それ自体」という区別を用いて興味深い検討を行う山崎友也「『憲法保障』とその『正しい解釈』」宍戸常寿＝林知更編『総点検 日本国憲法の 70 年』（岩波書店、2018 年）290-299 頁も参照。

24) 小嶋和司『憲法学講話』（有斐閣、1982 年）9 頁。

25) 蟻川恒正「（寄稿）新たな政治の空騒ぎ」朝日新聞 2023 年 1 月 24 日朝刊を参照。

26) これを蟻川・前掲注 25) は「立憲主義の逆説」と呼ぶ。

27) 蟻川・前掲注 25)。